

1500765-59.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MURIE SILVA APOLINARIO

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

GUSTAVO MURIE SILVA APOLINÁRIO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500765-59.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500765-59.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MURIE SILVA APOLINARIO

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

GUSTAVO MURIE SILVA APOLINÁRIO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 23h30, na Rua Visconde de

Cairu, nº 110, Vila Comercial, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, 9,41g (nove gramas e quarenta e um centigramas) de crack, subproduto da cocaína, divididos em 11 (onze) porções, além de 8,52g (oito gramas e cinquenta e dois centigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, tratando-se de substâncias capazes de causar dependência e cujos princípios ativos, Benzoilmetilecgonina e Tetrahydrocannabinol, estão relacionados em listas anexas à Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas de produção, cultivo, transporte, depósito, guarda, comercialização e fornecimento proibidos no território nacional. Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares realizavam patrulhamento por local comumente frequentado por traficantes e usuários de drogas e constataram que o acusado estava próximo a diversos indivíduos. Como ele procurou se afastar daquelas pessoas, suspeitaram que levasse objetos ilícitos consigo, abordaram-no e submeteram-no a busca pessoal.

Durante a revista, encontraram as substâncias entorpecentes acima descritas, no interior de uma das meias que o denunciado vestia. A maconha, em porção única; e o crack, dividido em 11 (onze) porções, uma delas grande e as demais, pequenas. Além das drogas, encontraram um telefone celular.

Indagado, o réu alegou que as drogas se destinavam ao próprio uso. Contudo, os milicianos não encontraram petrechos para o consumo sob a posse dele.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação das substâncias entorpecentes à comercialização.

A denúncia (fls. 115/118) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/109) e foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 119/120).

Citado (fls. 137), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 141), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 168/172).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 177).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 191/192).

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 191/192).

O Defensor, na sua manifestação final, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; pela aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal; pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; pela substituição dessa por restritiva de direitos; e pelo encaminhamento do réu a serviço de assistência social, para tratamento (fls. 191/192).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/12) e de exibição e apreensão (fls. 14/15), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 132/134), do laudo de exame do celular apreendido (fls. 143/166) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 132/134) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm Tetrahydrocannabinol e cocaína em sua composição.

Não há dúvida de que as drogas estavam sob a posse do denunciado, pois as declarações dele e das testemunhas policiais militares convergiram nesse sentido.

Resta verificar qual seria a sua destinação.

Interrogado (fls. 191/192), o réu, declarou que comprara as porções de crack e

maconha na região da linha férrea, por R\$ 110,00, e pretendia consumi-las. Para tanto, empregara dinheiro auferido com seu trabalho e a título de auxílio emergencial. Na ocasião do fato, estava consumindo drogas, quando foi abordado por policiais militares e agredido com pontapé na face. Afirmou que sofre perseguição e que a testemunha Thiago e policiais da BAEP têm desafeição por si. Declarou que nunca se desentendeu com policiais militares e não sabe que motivos eles têm para assediá-lo. Asseverou que a fotografia de cédulas de dinheiro existente na memória de seu telefone celular é captura de montante recebido a título de auxílio emergencial.

A adução de que sofre assédio policial não é fiável, pois as testemunhas informaram que não conheciam Gustavo e, à exceção da suposta agressão, não descreveram fatos estranhos à narrativa do réu.

A testemunha Thiago da Silva Ferreira (fls. 191/192), policial militar, informou que estavam em patrulhamento, quando viram o acusado em meio a moradores de rua, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Quando se aproximaram, Gustavo demonstrou nervosismo. Em razão disso, abordaram-no e submeteram-no a busca pessoal. Durante a revista, encontraram pedras fracionadas de crack, no calçado do pé direito dele. Indagado, o réu negou o tráfico de drogas. Disse que não encontraram maconha sob a posse dele, nem dinheiro, tampouco petrechos para o consumo da substância entorpecente. Informou que não conhecia o denunciado e nunca o abordara. Disse que, entre todos os presentes, concentraram-se em abordar o acusado, pois foi o que demonstrou maior inquietação com a aproximação da viatura. Lúcio Flávio Carnaúba (fls. 191/192), também policial militar, declarou que, durante patrulhamento, perceberam que havia várias pessoas em torno de um indivíduo, em local conhecido pelo tráfico de drogas. Abornaram-nos e o acusado despertou a atenção da equipe. Em razão disso, submeteram-no a revista e encontraram porções de crack e maconha, no interior da meia dele. Disse não se lembrar se o denunciado confirmou a posse da droga. Informou que não encontraram petrechos para o consumo das substâncias entorpecentes, nem dinheiro sob a posse dele. Negou que o tenham agredido. Asseverou que não o conhecia e nunca o vira naquela região. Disse que outros indivíduos foram abordados nas mesmas condições de tempo e local, mas não se lembra se algum deles portava dinheiro. É certo que os milicianos apresentaram relatos conflitantes quanto à abordagem a terceiros, a posse de maconha e a confirmação de posse das substâncias entorpecentes, pelo denunciado.

Todavia, as dissonâncias são irrelevantes pois o acusado informou que as porções de crack e de maconha estavam sob a sua posse, assim como descreve a denúncia. Portanto, como se expôs anteriormente, não há dúvida de que ele levava as drogas consigo.

A adução de que sofre perseguição é incompatível com as declarações das testemunhas, que disseram que não conheciam Gustavo anteriormente ao fato. Não parece razoável que os milicianos tenham mentido para prejudicar o réu, pois não descreveram outras circunstâncias que o desfavorecessem, como a comercialização das substâncias entorpecentes a terceiros. Narraram, apenas, a posse das drogas. Conquanto Gustavo tenha alegado que as porções de crack e maconha se destinavam ao próprio consumo, a grande quantidade demonstra que serviriam ao fornecimento a terceiros.

A quantidade de crack apreendida seria suficiente para a confecção de aproximadamente 50 (cinquenta) porções, pedras, individuais. Nesse sentido são esclarecedores os casos objetos dos acórdãos a seguir, em que cada pedra da droga pesava, em média, 0,18g (dezoito centigramas) e 0,14g (quatorze centigramas) respectivamente:

(...) Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em posse de 32 pedras de crack, com peso bruto aproximado de 5,90 gramas (...). (TJSP; 16ª Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 1500396-09.2018.8.26.0571; Relator: Desembargador Aranha Filho; j. 13.06.2019).

(...) guardava e tinha em depósito drogas, 117 "trouxinhas" de crack, com peso bruto total de 17 gramas e 1 papelote de maconha, com peso bruto total de 1 grama, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar (...). (TJSP; 6ª Câmara Criminal; Apelação nº 993080151334; Relator: Desembargador Domingos Parra Neto; j. 30/04/2010).

Com a maconha apreendida seria possível confeccionar aproximadamente 08 (oito) porções individuais, consoante se verifica nos casos tratados nos julgados a seguir, em que cada porção individual pesava, em média, 0,912g (novecentos e doze miligramas) e 0,91g (noventa e um centigramas) respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 16ª Câmara Criminal; Apelação nº 990081469807; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papелotes plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 36ª Câmara Criminal; Apelação nº 990093256975; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

É difícil acreditar que o acusado adquirisse tamanha quantidade, de uma única vez, para o próprio consumo, pois não há prova de que exercesse atividade lícita remunerada, nem de que portasse petrechos para o consumo.

Inobstante a informação de que recebeu auxílio emergencial, não se pode ignorar que o último pagamento ocorrera aproximadamente 15 dias antes da sua prisão em flagrante delito e foi de modestos R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (fls. 201). Supondo que o réu fosse usuário severo de crack, circunstância que poderia justificar a compra de quantidade suficiente para 50 porções, seria improvável que reservasse o valor por 15 dias, sem o despendar imediatamente na compra de drogas. Portanto, a quantidade suficiente para o fracionamento em aproximadamente 50 porções evidencia que as porções de crack se destinavam ao fornecimento a terceiro. Irrelevante que não portasse lâmina ou instrumento para o corte, pois o fracionamento da droga usualmente se dá manualmente, no modo comumente designado por traficantes e usuários como quebra na unha.

Prescinde-se de evidência de que vendera substâncias entorpecentes anteriormente à abordagem, como a posse de dinheiro, pois o simples porte da droga com a intenção de fornecimento a terceiros basta para a configuração da conduta criminosa.

Ao levar consigo e guardar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou ações abstratamente previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em que pese a argumentação do Ministério Público, o réu é tecnicamente primário e não há evidência de que integre organização criminosa.

A decisão condenatória proferida no processo de conhecimento nº 1500884-88.2018.8.26.0583 (fls. 57) é insuficiente para demonstrar a dedicação à prática delitiva, pois não transitou em julgado.

Não se desconhece entendimento jurisprudencial no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento bastam para evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa (v.g. AgRg no HC 517904/TO, STJ). Todavia, tal entendimento não se coaduna com o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF). Como o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva. A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) é elevada para esta modalidade de delito, haja vista a variedade de substâncias entorpecentes e a especial nocividade do crack.

Não obstante a culpabilidade elevada, os elementos que a determinam serão ponderados na terceira etapa do cálculo da sanção. Para evitar bis in idem, deixa-se de exasperar a pena-base da acusada sob este fundamento.

As circunstâncias e as consequências da ação são normais para esta espécie de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o acusado tinha menos de 21 anos ao tempo do fato (fls. 136 e 187) (art. 65, I, CP). Inviável, contudo, a atenuação da pena base para alguém do mínimo legal, nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ). Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 1/6 (um sexto). Aplica-se o redutor mínimo, em razão da variedade de drogas e da nocividade elevada do crack.

Ademais, ainda que a condenação anterior por tráfico de drogas não permita, pela ausência de trânsito em julgado, que se conclua pela dedicação do réu à atividade criminosa, por certo, revela que a apreensão de drogas sob sua posse não foi um fato isolado, tal como se espera de um traficante eventual, de modo que, se não apenas adequadamente, adotará a habitualidade da conduta como meio de vida. Lembre-se que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser ponderadas para mensuração do quantum de diminuição. Nesse sentido:

Na falta de indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do patamar de redução ou, até mesmo, para impedir a aplicação da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. (STJ; HC 364113/SP; Quinta Turma; Ministro Ribeiro Dantas; j. 04.10.2016).

Com a diminuição, passam-se as sanções para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da sanção e a culpabilidade elevada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos objetivo (quantum da sanção) e subjetivo (culpabilidade elevada), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar GUSTAVO MURIE SILVA APOLINÁRIO, nascido aos 31/03/2001, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Alessandra Leandro da Silva e de Fábio José Apolinário, inscrito no Registro Geral nº 57.395.068-4 SSP/SP e no CPF nº 237.139.968-06 (fls. 20), pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. A condenação recente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 57), embora insuficiente para ensejar reincidência e demonstrar a dedicação à atividade criminosa, é indício consistente de reiteração da conduta. O indício de reiteração e a culpabilidade elevada denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de retomada do tráfico. Tais circunstâncias determinam a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas

nos próximos cinco anos.

Indefiro o pedido de encaminhamento a tratamento, pois inexistente recomendação médica para tanto (art. 47, Lei nº 11.343/06).

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo a restituição do celular apreendido ao denunciado ou pessoa por ele indicada, após o trânsito em julgado.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 141).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.

Presidente Prudente, 05 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA